

1500583-56.2022.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... indica para uma guarda com a intenção de tráfico, venda.

O crime de tráfico ilícito de drogas traz em seu tipo penal vários verbos que exprimem as formas de conduta puníveis, algumas de natureza instantânea, outras permanentes, não sendo necessário para sua configuração tenha a agente efetuado a venda. Basta que a possua ou tenha em depósito com o fim de colocá-la em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500583-56.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2142345/2022 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 25181792 -

DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 2142345 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ MARCOS PEREIRA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

JOSÉ MARCOS PEREIRA DOS SANTOS foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, porque no dia 25 de maio de 2022, na rua Doutor Ciro Berlinck, nº 12, Vila Esperança, nesta cidade e Comarca, nas imediações de um estabelecimento de ensino, trazia consigo, com a finalidade de comércio, 125 porções de maconha e 60 porções de cocaína, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em

desacordo com determinação legal e regulamentar.

Devidamente notificado, o acusado apresentou defesa preliminar a fls. 135/136.

Recebida a denúncia aos 21 de julho de 2022 (fl. 143), deu-se a regular instrução do processo.

Durante a instrução processual ouviram-se duas testemunhas de acusação e, ao final, promoveu-se o interrogatório do acusado (fl. 225).

Em seguida as partes apresentaram alegações finais.

A acusação requereu a procedência parcial da ação, certa de que as provas dos autos estão em sintonia e autorizam a condenação, afastando-se, contudo, a causa de aumento de pena denunciada (fls. 228/233).

A defesa postulou o reconhecimento de atenuante e de causa de diminuição de pena, além de aplicação de regime mais brando e sua substituição por pena restritiva de direitos (fls. 237/254).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do delito contra a saúde pública está plenamente comprovada.

Os laudos de exame químico toxicológico (fls. 63/68) descreveram e concluíram que as substâncias analisadas são maconha e cocaína, caracterizadas por meio de análises químicas e cromatográficas.

Ademais, está evidente que o elemento responsável pelos efeitos farmacológicos das ervas estavam presentes.

Pelos testemunhos colhidos a autoria também se evidenciou.

O acusado em seu interrogatório admitiu a prática da infração e se mostrou arrependido. Escusou-se da imputação baseado em argumentos incapazes de retirar sua responsabilidade criminal.

Sua confissão está em harmonia com as demais provas. Vejamos.

O Policial Militar Josinei esclareceu que naquela ocasião realizava patrulhamento de rotina quando abordou dois indivíduos numa motocicleta. Realizada revista pessoal, encontrou em poder do acusado diversas porções de maconha e cocaína, que estavam guardadas no interior da mochila que ele carregava.

Indagado sobre a droga, o acusado admitiu que naquele dia contratou um mototáxi para levá-lo até o Bairro Enedina Cortês, lugar onde havia adquirido aqueles entorpecentes visando ao tráfico de drogas.

Por sua vez, a testemunha Antonio disse que trabalha como motoboy. Naquela ocasião acertou uma viagem com acusado, pessoa a quem conhece como "Mazinho", para leva-lo até os "predinhos" existentes no Bairro Águas Claras. Lá chegando, o acusado desceu ao lugar de destino e ele permaneceu esperando no estacionamento dos prédios. Após 15 minutos o acusado retornou, momento em que seguiram viagem de retorno em direção à casa do acusado. Contudo, durante o trajeto foram abordados por policiais militares.

Acrescentou que os policiais localizaram com o acusado uma mochila e, após revistarem o objeto, localizaram e apreenderam diversas porções de drogas. Por fim declarou que desconhecia que o acusado transportava as drogas, bem como afirmou que o presenciou admitindo aos policiais a propriedade do entorpecente.

Nada existe nos autos a demonstrar que os policiais responsáveis pela prisão do acusado tivessem qualquer motivo para imputar a ele, indevidamente, a prática de crime, em especial da gravidade do denunciado. Por seus conteúdos, eles são suficientes a comprovar a situação de traficância.

Por isso mesmo, a intenção de comerciar fica consubstanciada visto que tais provas apontam claramente para esta finalidade do agente. Não há nada que possa desabonar o depoimento dos policiais envolvidos, pois seus atos presumem-se legítimos por força de princípio administrativo.

"Não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria contra-senso credenciar o Estado alguém para atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna

jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito".

Destarte, o argumento de que seus depoimentos estariam comprometidos pelo fato de terem o dever legal de justificar sua atividade não pode ser aceito. Se o fosse, estaria estabelecido preconceito odioso em relação a pessoas que auxiliam a justiça na busca da verdade real.

Assim, seus depoimentos são analisados e cotejados com os demais elementos carreados aos autos, sem maior ou menor relevância pelo fato de serem agentes de segurança do Estado, responsáveis pela repressão ao crime.

Neste diapasão, tem se manifestado a jurisprudência ao tratar do depoimento policial. Veja-se:

"A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF - RT 68/64).

"Não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria contra-senso credenciar o Estado alguém para atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese dos desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito" (Tacrím/SP - JUTACRIM 30/221).

Não foram ouvidas testemunhas de defesa capazes de descaracterizar as provas orais colhidas.

A finalidade de traficar está bem evidenciada, cristalina. A quantidade da droga encontrada, a forma como estava acondicionada em porções prontas para a venda, a diversidade de espécies, as circunstâncias como foi surpreendido, sua confissão, tudo indica para uma guarda com a intenção de tráfico, venda.

O crime de tráfico ilícito de drogas traz em seu tipo penal vários verbos que exprimem as formas de conduta puníveis, algumas de natureza instantânea, outras permanentes, não sendo necessário para sua configuração tenha a agente efetuado a venda. Basta que a possua ou tenha em depósito com o fim de colocá-la em circulação, incorrendo, assim, em uma das figuras do tipo.

Em escólio à norma em apreço, o renomado VICENTE GRECO FILHO leciona a respeito da prescindibilidade da ocorrência da venda do produto, assim asseverando:

"Para a existência do delito não há necessidade de ocorrência do dano. O próprio perigo é presumido em caráter absoluto, bastando para a configuração do crime que a conduta seja subsumida num dos verbos previstos" (Tóxicos - Prevenção - Repressão. Saraiva, 1987, p. 81.)

A esse respeito, esclarecedor é o seguinte julgado:

"Para a consumação do delito de comércio clandestino de entorpecente, não importa que o produto não tenha sido distribuído à venda. Consuma-se ele embora não tenha resultado o dano. Seu não-exaurimento, porém, é irrelevante, vez que não, ficou afastada a real periclitación do bem jurídico penalmente protegido. Nem se há de falar na hipótese de crime impossível." (RT 401/75)

Nas modalidades que configuram crime permanente, ou seja, expor a venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, etc... evidenciado o início da execução, tem-se o crime por consumado.

A propósito, os ensinamentos do ilustre doutrinador MENA BARRETO, que bem demonstram o entendimento pacífico sobre a matéria:

"Afinal, cabe nesta oportunidade lembrar, igualmente, algumas ações delituosas que têm caráter formal ou de consumação antecipada e que por via de consequência, dada a sua não-fragmentação, desautorizam a aceitação de tentativa. É o caso, verbi gratia, das relativas à guarda, ao depósito ou ao transporte de tóxicos, além da simples posse (trazer consigo)" (Lei de Tóxicos, Comentários por Artigo. Freitas Bastos, 1996, p. 74.).

Ora, a conduta praticada pelo acusado amolda-se perfeitamente à figura "trazer consigo", prevista no tipo penal do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

No mais, a apreensão de apreciável quantidade de substância entorpecente, conduz à segura conclusão de estar configurado o delito de tráfico.

Concluída a motivação, à dosagem da pena devem ser atendidas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal.

Em fundamentação à aplicação da pena saliento que a reprovabilidade da conduta praticada pelo condenado não justifica aumento nas penas-base.

Ele não ostenta antecedentes criminais e os autos não fornecem elementos seguros para análise da conduta social e da personalidade do agente.

Os motivos, circunstâncias e consequências do crime não diferenciam, quando comparados com outros da mesma espécie, estes fatos de outros praticados em situações semelhantes, não merecendo assim, este, maior reprovabilidade. Não há participação de vítima no tráfico a ser considerada na dosimetria da pena.

Ausentes as circunstâncias judiciais acima expostas, que devam levar à exacerbação das penas-base, fixo-as no patamar mínimo legal.

Não há atenuantes ou agravantes genéricas a considerar na segunda fase, pois embora presente a atenuante da confissão, suas penas já se encontram em seus limites mínimos, impedindo maior redução neste momento.

Na etapa derradeira, não deve ser reconhecida a causa especial de aumento denunciada, prevista no artigo 40, inciso III, da lei de drogas. Isto porque o acusado foi surpreendido enquanto trafegava com uma motocicleta pela via pública. Logo, ainda que próximo ao local indicado no laudo (fls. 77/79), esta circunstância não significa que visava atingi-lo, posto que não existem elementos na direção de que o efetivo comércio da droga se realizaria naquele lugar.

O condenado é primário, portador de bons antecedentes criminais e, nestes autos, não se demonstrou que ele tenha envolvimento ou integre organização criminosa.

Logo, amolda-se na hipótese da aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Assim sendo, as penas serão diminuídas em 2/3 (5 anos - 2/3 = 1 ano e 08 meses - 500 dias - 2/3 = 166 dias).

Para início do cumprimento da pena fixo o regime aberto, levando em consideração as circunstâncias judiciais favoráveis, a primariedade do agente, o reconhecimento do tráfico privilegiado e do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus nº 596.603:

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDIVIDUAL E COLETIVO. ADMISSIBILIDADE.

DIRETRIZES REGISTRADAS PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641 (PLENO).

PRECEDENTES DESTES TRIBUNAL DA CIDADANIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HIPÓTESES DE

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, LEI N. 11.343/2006).

TRÁFICO. DEFINIÇÃO LEGAL (ART. 112, §5º, LEI N. 7.210/1984). CRIME NÃO HEDIONDO.

CONSECTÁRIOS LÓGICOS EM RAZÃO DESSE RECONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS

TRIBUNAIS SUPERIORES E SÚMULAS DE JURISPRUDÊNCIA. FORÇA NORMATIVA. ESTUDO DO

INSTITUTO CONECTAS E DADOS ESTATÍSTICOS QUE CONFIRMAM O DESCUMPRIMENTO REITERADO

PELO TRIBUNAL IMPUGNADO. DESRESPEITO AO SISTEMA DE PRECEDENTES. SEGURANÇA JURÍDICA

E ESTABILIDADE. ISONOMIA DO JURISDICIONADO. BUSCA À RACIONALIDADE PUNITIVA.

PREDICATIVO ÍNSITO AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA

DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME PRISIONAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA

PENA. PROPORCIONALIDADE. 1. Ante a necessidade de salvaguardar um dos direitos fundamentais mais preciosos do ser humano, a liberdade, o Supremo Tribunal Federal,

ao julgar o HC n. 143.641/SP, rompeu com a resistência registrada nos seus precedentes, quanto à inadmissibilidade do uso do writ constitucional de maneira

coletiva. Na oportunidade, assentaram-se diretrizes a respaldar o maior espectro do remédio heroico, entre elas: a existência de relações sociais massificadas e

burocratizadas, cujos problemas estão a exigir soluções a partir de remédios processuais coletivos, especialmente para coibir ou prevenir lesões a direitos de

grupos vulneráveis; o fortalecimento da abordagem coletiva, em atendimento a maior isonomia às partes em litígio e em prestígio à celeridade processual, mitiga as

dificuldades estruturais do acesso das coletividades ao Poder Judiciário. 2. A moldura fática trazida pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo - mais de mil

presos, que, a despeito da reconhecida prática de crime de tráfico privilegiado, cumprem pena de um ano e oito meses, em regime fechado, com respaldo exclusivo no

ultrapassado entendimento de que a conduta caracteriza crime assemelhado a hediondo - permite solução coletiva, por reproduzirem a mesma situação fático-jurídica.

Precedente (HC n. 575.495/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T, julgado em 2/6/2020, DJe 8/6/2020). 3. Há anos são perceptíveis, em um segmento da jurisdição criminal, os reflexos de uma postura judicial que, sob o afirmado escudo da garantia da independência e da liberdade de julgar, reproduz política estatal que se poderia, não sem exagero, qualificar como desumana, desigual, seletiva e preconceituosa. Tal orientação, que se forjou ao longo das últimas décadas, parte da premissa equivocada de que não há outro caminho, para o autor de qualquer das modalidades do crime de tráfico – nomeadamente daquele considerado pelo legislador como de menor gravidade –, que não o seu encarceramento. 4. Segundo a interpretação, consolidada e antiga do Supremo Tribunal Federal (HC n. 111.840, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 17/12/2013), conforme à Constituição da República, não é considerado hediondo o delito de tráfico de drogas, na modalidade prevista no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006 (caracterizada pela quantidade de drogas apreendida não elevada e por ser o agente primário, sem antecedentes penais e sem envolvimento com atividade ou organização criminosa). 5. Em decorrência dessa interpretação, que sobreleva os princípios da presunção de inocência e da individualização da pena, a natureza não hedionda do crime em exame desautoriza prisão preventiva sem a análise concreta dos requisitos do art. 312 do CPP (HC n. 104.339, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 06/12/2012), afasta a proibição, prevista art. 44 da Lei 11.343/2006, de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos (HC n. 97.256, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Ayres Britto, DJe 15/12/2010), e impõe, portanto, tratamento penal com "contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa" (HC n. 118.533, Tribunal Pleno, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe 19/9/2016). 6. Quanto ao regime inicial para o cumprimento da pena, é clara e reiterada a dicção de enunciados sumulares dos Tribunais Superiores, segundo os quais "A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" (Sum. 718 do STF), "A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea" (Sum. 719 do STF) e "É vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade do delito" (Sum. 440 do STJ). 7. Esses julgados, por força do art. 927, III e V, do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal em razão da norma de abertura positivada no art. 3º do CPP, devem ser observados por juízes e tribunais do país, em nome da segurança jurídica, da estabilidade das decisões do Poder Judiciário, da coerência sistêmica e da igualdade de tratamento dos jurisdicionados, que não podem ficar à mercê de interpretações divergentes, sobre questões de cunho eminentemente jurídico, das que lhes conferiram os órgãos de cúpula do Poder Judiciário, incumbidos, por comando constitucional, da função de uniformizar a interpretação e a aplicação da Constituição da República e das leis federais (arts. 102, III e 105, III). 8. A partir da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, que conferiu nova redação ao art. 112, § 5º, da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), "Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006". 9. Deveras, não condiz com a racionalidade punitiva, ínsita a um Estado Democrático de Direito, que a todo e qualquer autor de tráfico de drogas se imponha o cumprimento de sua pena em estabelecimento penal, em regime fechado, e sem direito a qualquer alternativa punitiva, mesmo se todas as circunstâncias judiciais e legais sejam reconhecidas a seu favor (quantidade pequena de droga, primariedade e bons antecedentes do agente, além de não demonstração de seu envolvimento em atividade ou organização criminosa). 10. E não há de ser esse o proceder de agentes do Estado a quem se confia o exercício da nobre função de dizer o Direito, algo que, no âmbito da jurisdição criminal – que expressa o poder punitivo estatal – reclama dose ainda maior de serenidade e ausência de preconceitos. 11. A individualização da sanção penal (alçada a direito fundamental, inscrito no art. 5º, XLVI da Constituição da República) não se limita à quantidade da pena; o seu regime e a

modalidade da reprimenda imposta também compõem essa ideia, que carrega em si a proporcionalidade da pena. Se o Código Penal determina que, fixada a sanção em patamar inferior a 4 anos de reclusão, o regime inicial de pena há de ser o aberto quando as circunstâncias forem todas favoráveis ao agente (art. 33, § 2º c/c 59, do CPB), permitindo também substituir a reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CPB), não há razão para impor-se a condenados pela modalidade mais tênue do crime de tráfico de entorpecentes o mesmo regime de pena que, ex vi lege, se costuma impingir somente a quem é condenado por outros crimes, ou mesmo por tráfico, a mais de 8 anos de pena, ou a reincidentes ou portadores de circunstâncias desfavoráveis. 12. A documentação, trazida em aditamento à impetração, alude a 1100 homens e mulheres que cumprem pena em regime fechado no sistema penitenciário do Estado de São Paulo, e sem lhes haver sido autorizada a conversão da privativa de liberdade em restritiva de direitos, a despeito de terem sido condenados à sanção mínima do tráfico privilegiado (1 ano e 8 meses de reclusão), ou, quando muito, a uma pena menor que 4 anos de reclusão. A menos que cumpram pena por outro motivo, são pessoas que se encontram indevidamente recolhidas ao precário sistema penitenciário, onerando ainda mais a sociedade, que poderia se beneficiar com serviços comunitários, houvessem as respectivas sanções reclusivas sido convoladas em restritivas de direito. 13. Se a lei é, na visão de julgadores, benevolente com algum tipo de crime, compete ao Congresso Nacional, legitimado pelo voto popular, modificá-la (sempre sujeito, evidentemente, ao controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal). Não cabe ao Poder Judiciário, o uso de discursos metajurídicos de matiz ideológico ou moral, para incrementar o rigor do sistema punitivo e para contornar, com argumentos aparentemente jurídicos, os limites impostos pela lei penal e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, os quais, como visto, pela Constituição da República têm a especial competência para interpretar e uniformizar a lei federal e a Constituição em última instância, ante idênticas situações fáticas. 14. Estudo feito pelo Instituto Conectas (relatório disponível no sítio do instituto na web) conclui que “ainda que a decisão do STF no HC 118.533 tenha sido o reconhecimento do tráfico privilegiado como um crime comum, afastando-se a hediondez dos casos em que há aplicação da causa de diminuição do parágrafo 4º do art. 33, com a presente pesquisa verifica-se que juízes de primeira instância, em São Paulo, continuam aplicando tratamento desproporcional ao delito, em comparação com outros delitos sem violência de igual pena.” Alguns julgados – prossegue o relatório – “são expressos em sua afronta à jurisprudência dominante das cortes superiores, tecendo palavras fortes contra a

evolução interpretativa e constituindo, dentro da sua esfera de poder, um espaço blindado contra o tratamento proporcional aos condenados por tráfico de drogas, em qualquer grau.” 15. Pelos dados do Núcleo de Segunda Instância e Tribunais Superiores - Brasília/DF, a Defensoria Pública de São Paulo em 2019, dos 11.181 habeas corpus impetrados no STJ, a ordem foi concedida em 6.869 feitos, 61,43% das impetrações. Mais ainda, aquela Defensoria evidenciou que, no período da pandemia, conforme Levantamento do Núcleo Especializado de Situação Carcerária da Defensoria Pública de São Paulo, em casos de reconhecido tráfico de menor monta (pouca quantidade de drogas, réus com bons antecedentes e sem provas de anterior atividade ilícita e de integração a organização criminosas), de 64 casos em que Câmaras Criminais do TJSP mantiveram a condenação de acusados por tráfico privilegiado, 53 foram reformadas pelo STJ, ou seja, cerca de 82,80% dos pacientes obtiveram decisão concessiva. 16. Esses dados são a tradução, inequívoca e indesmentível de que o volume de trabalho das Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça, ocupadas em mais de 50% por habeas corpus oriundos do Tribunal de Justiça de São Paulo (dos 68.778 habeas Corpus distribuídos no STJ em 2019, 35.534 vieram daquele Tribunal), em boa parte se resume a simplesmente reverter decisões que, contrárias às súmulas e à jurisprudência das Cortes Superiores, continuam a grassar, crescentemente, em algumas das 16 Câmaras Criminas daquele Tribunal. 17. Essa insistente desconsideração de alguns órgãos judicantes às diretrizes normativas derivadas das Cortes de Vértice produz um desgaste permanente da função jurisdicional, com anulação e/ou repetição de atos, e implica inevitável lesão financeira ao erário,

bem como gera insegurança jurídica e clara ausência de isonomia na aplicação da lei aos jurisdicionados. 18. Em suma, diante da mesma situação factual – tráfico de pequena monta, agente primário, sem antecedentes penais, sem prova de vínculo com organização criminosa e de exercício de atividade criminosa (que não seja, é claro, a específica mercancia ilícita eventual que lhe rendeu a condenação) –, há de reconhecer-se que: 18.1. A Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), em seu art. 112, § 5º (com a redação que lhe conferiu a Lei n. 13.964/2019) é expressa em dizer que “§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006”; 18.2. O Ministério Público, a par da função exclusiva de exercitar a ação penal pública, é também constitucionalmente incumbido da “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (art. 127, caput, da C.R.), e deve agir de acordo com critérios de objetividade, compromissado, pois, com o direito (custos iuris) e com a verdade (obbligo di verità, na dicção de LUIGI P. COMOGLIO e VLADIMIRO ZAGREBELSKY, Modelo accusatorio e deontologia dei comportamenti processuali nella prospettiva comparatistica. Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale. Milano: Giuffrè, ano 36, fasc. 2 – aprile-giugno/1993, p. 484). Logo, a acusação formulada pelo Ministério Público há de consubstanciar uma imputação responsavelmente derivada da realidade fático-jurídica evidenciada pelo simples exame do inquérito policial, muitas vezes já indicativa de que não se cuida de hipótese de subsunção da conduta do agente ao crime de tráfico de drogas positivado no caput do art. 33 da LAD. 18.3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores – quer por meio de súmulas (verbetes n. 718 e 719 do STF e 440 do STJ), quer por meio de julgamentos proferidos pela composição Plena do Supremo Tribunal Federal, seguidos por inúmeros outros julgamentos da mesma Corte e do STJ – é uníssona e consolidada no sentido de que: 18.3.1. Não se pode impor regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito e sem a idônea motivação, que não pode decorrer da mera opinião do julgador; 18.3.2. O condenado por crime de tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a pena inferior a 4 anos de reclusão, faz jus a cumprir a reprimenda em regime inicial aberto ou, excepcionalmente, em semiaberto, desde que por motivação idônea, não decorrente da mera natureza do crime, de sua gravidade abstrata ou da opinião pessoal do julgador; 18.3.3. O condenado por crime de tráfico privilegiado, nas condições e nas ressalvas da alínea anterior, faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; 18.3.4. O autor do crime previsto no art. 33, § 4º da LAD não pode permanecer preso preventivamente, após a sentença (ou mesmo antes, se a segregação cautelar não estiver apoiada em quadro diverso), porque: a) O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal – e copiosa jurisprudência das Cortes Superiores – afastou a vedação à liberdade provisória referida no art. 44 da LAD; b) Não é cabível prisão preventiva por crime punido com pena privativa máxima igual ou inferior a 4 anos (art. 313, I do Código de Processo Penal; c) O tempo que o condenado eventualmente tenha permanecido preso deverá ser computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade (art. 387, § 2º do CPP), o que, a depender do tempo da custódia e do quantum da pena arbitrada, implicará imediata soltura do sentenciado, mesmo se fixado o regime inicial intermediário, ou seja, o semiaberto (dado que, como visto, não se mostra possível a inflicção de regime fechado ao autor de tráfico privilegiado). 19. Essas são, portanto, as diretrizes que devem ser observadas – e normalmente o são, pela maioria de juízes e tribunais de todo o país –, por decorrerem de precedentes qualificados das Cortes Superiores (súmulas de jurisprudência, julgamentos pelo Tribunal Pleno do STF, recursos especiais julgados sob o rito dos recursos repetitivos do STJ, e extraordinários em repercussão geral, pelo STF), sobre questões jurídicas assentadas a partir da mesma situação fática, sempre ressalvada, naturalmente, a eventual indicação de peculiaridades do caso examinado, a permitir, mediante idônea e responsável motivação, distinguir a hipótese em julgamento da que fora decidida nos referidos precedentes. 20. Na espécie, a gravidade excepcional do delito não se sustenta, visto que o crime foi praticado em circunstâncias inerentes à caracterização da própria figura delitiva

em apreço e, embora apreendidas cocaína e crack, a quantidade da droga, ao contrário do afirmado, não foi relevante (5,6 g no total). 21. Habeas Corpus concedido, para: 21.1. Em relação ao paciente individualizado na impetração, fixar o regime aberto como modo inicial de cumprimento da pena. 21.2. Em relação aos presos que, conforme informação da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, se encontrem na mesma situação (condenados, por delito de tráfico privilegiado, a 1 ano e 8 meses, em regime fechado), fixar o regime aberto. 21.3. Em relação aos presos condenados, pelo delito de tráfico privilegiado, a penas menores do que 4 anos de reclusão – salvo os casos do item anterior – determinar que os respectivos juízes das Varas de Execução Penal competentes e responsáveis pela execução das sanções dos internos reavaliem, com a máxima urgência, a situação de cada um, de modo a verificar a possibilidade de progressão ao regime aberto em face de eventual detração penal decorrente do período em que tenham permanecido presos cautelarmente. 21.4. Aos condenados que atualmente cumprem pena por crime de tráfico privilegiado, em que se reconhecem todas as circunstâncias como favoráveis, e aos que vierem a ser sancionados por tal ilicitude (mesmas circunstâncias fáticas), determinar que não se imponha – devendo haver pronta correção aos já sentenciados – o regime inicial fechado de cumprimento da pena. Determinação para que se dê cumprimento desta ordem de Habeas Corpus, inclusive para que se providencie, junto aos respectivos juízos, a imediata expedição de alvarás de soltura aos presos que, beneficiados pelas medidas ora determinadas, não estejam presos por outros motivos. (HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1) RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 04/09/2020).

E mais:

“HABEAS CORPUS” – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI Nº 11.343/2006, ART. 33, § 4º)– CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – UTILIZAÇÃO DESSE FATOR DE REDUÇÃO, EM GRAU MENOS FAVORÁVEL, SEM ADEQUADA JUSTIFICAÇÃO DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA PENAL – QUANTIDADE (OU NATUREZA) DAS DROGAS APREENDIDAS COM O CONDENADO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL A SER PONDERADA, SOMENTE, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL (LEI Nº 11.343/2006, ART. 42)– CRITÉRIO QUE NÃO PODE SER UTILIZADO, DE NOVO, SOB PENA DE OFENSA AO POSTULADO QUE VEDA O “BIS IN IDEM”, NA TERCEIRA FASE DA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA, PARA JUSTIFICAR A APLICAÇÃO, EM GRAU MENOS FAVORÁVEL AO CONDENADO, DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA (LEI Nº 11.343/2006, ART. 33, § 4º)– PRECEDENTES – CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS NOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33, “CAPUT” E § 1º, E NOS ARTS. 34 A 37, TODOS DA LEI DE DROGAS – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA REGRA LEGAL QUE VEDA, “IN ABSTRACTO” (ART. 33, § 4º, E ART. 44), ESSA CONVERSÃO (HC 97.256/RS) – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA – POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, NOS CASOS DE TRÁFICO PRIVILEGIADO DE ENTORPECENTES, EM REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO QUE O REGIME FECHADO (HC 111.840/ES) – CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE HIPÓTESE DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO – PEDIDO DEFERIDO EM PARTE. . - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 97.256/RS, Rel. Min. AYRES BRITTO, reconheceu a inconstitucionalidade de normas constantes da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), no ponto em que tais preceitos legais vedavam a conversão, pelo magistrado sentenciante, da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos. - O Poder Público, especialmente em sede penal, não pode agir imoderadamente, pois a atividade estatal, ainda mais em tema de liberdade individual, acha-se essencialmente condicionada pelo princípio da razoabilidade, que traduz limitação material à ação normativa do Poder Legislativo. . - Atendidos os requisitos de índole subjetiva e os de caráter objetivo previstos no art. 44 do Código Penal, torna-se viável a substituição, por pena restritiva de direitos, da pena privativa de liberdade imposta aos condenados pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, “caput” e § 1º, e 34 a 37, todos da Lei nº 11.343/2006. - Possibilidade de o condenado pelo crime de tráfico privilegiado de entorpecentes (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) iniciar o cumprimento da pena em regime menos gravoso que o regime fechado. Precedente do Plenário (HC 111.840/ES, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, “Informativo/STF nº 672”).

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação

penal, para o fim de CONDENAR JOSÉ MARCOS PEREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data, face sua situação econômica.

Vislumbrando a presença dos pressupostos de aplicação das penas restritivas de direito, nos termos dos artigos 43 e seguintes do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Primeiramente, pela prestação de serviços gratuitos à comunidade, devendo o condenado prestar uma hora de tarefa por dia de condenação, devendo tal serviço, ainda, ser prestado aos sábados, domingos e feriados, ou dias úteis, desde que não haja prejuízo a sua jornada normal de trabalho.

Caberá ao Juiz da Execução designar a entidade ou programa comunitário ou estatal, junto ao qual o condenado irá trabalhar gratuitamente.

Ao depois, nos termos do § 1º, do artigo 45, do Código Penal, pela pena de 1 (um) salário-mínimo, a ser destinado a entidade pública ou privada com destinação social, indicada pelo Juízo da Execução.

O sentenciado poderá apelar em liberdade porque respondeu ao procedimento nesta condição e o Juízo não vislumbra como presentes os requisitos da prisão cautelar.

Concedo a ele os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Com o trânsito em julgado, promovam-se as comunicações de praxe e adote o necessário ao cumprimento da pena.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE.

Bragança Paulista, 31 de outubro de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA